

ADR nel Nord degli Stati Uniti ed adempimenti degli avvocati neutri e degli accompagnatori alle procedure

Avv. Carlo Alberto Calcagno

Mediation is neither therapy nor a "day in court." Rather, mediation should provide a safe environment for the parties to air their differences and reach a mutually agreeable resolution. Mediators are NOT judges. Their role is to manage the process through which parties resolve their conflict, not to decide how the conflict should be resolved. They do this by assuring the fairness of the mediation process, facilitating communication, and maintaining the balance of power between the parties. Department of Justice, ADA Mediation Program.

Sono davvero dispiaciuto che quella parte dell'avvocatura italiana che si è fatta promotrice della dichiarazione di incostituzionalità, abbia deciso di non misurarsi con uno strumento che ha ad esempio trasformato la vita professionale degli avvocati americani a partire dall'attività procuratoria per giungere a quella più propriamente consulenziale.

È vero che bisogna essere pronti ad affrontare gli ADR, anche dal punto di vista organizzativo; ma si potrebbe d'altro canto sostenere più banalmente che *"chi dorme non piglia pesci"*, e che se i clienti non telefonano e non pagano magari può esserci una ragione che non è strettamente legata alla crisi economica, ma ad un servizio che a partire perlomeno dagli anni '90 è percepito dagli assistiti come poco soddisfacente.

È certo che i legali americani hanno probabilmente un differente approccio mentale, basta leggere la regola principale in tema di attività consulenziale, la rule 2.1 (Advisor) delle *Model Rules of Professional Conduct American Bar (2012)*¹: *"In representing a client, a lawyer shall exercise independent professional judgment and render candid advice². In rendering advice, a lawyer may refer not only to law but to other considerations such as moral, economic, social and political factors, that may be relevant to the client's situation"*.

¹ Il 15 luglio del 1999 la Commissione ADR dell'Institute for Dispute Resolution (CPR) in collaborazione con la Georgetown University Law Center ha stilato un documento (*Proposed Model Rule of Professional Conduct for the Lawyer as Third Party Neutral*) che è stato recepito dalla Commissione dell'American Bar Association ed oggi fa parte delle *Model Rules of Professional Conduct American*. Le regole dell'ABA predette sono state adottate da 44 Stati su 50 in toto, in parte o con alcune aggiunte o modifiche.

² Per *"candid advice"* si intende una consulenza libera da pregiudizi, imparziale, caratterizzata da apertura e sincerità di espressione, senza riserve.

Il commento alla regola ci spiega tra le altre cose che:

- un consulto legale formulato in termini strettamente giuridici può avere scarsa utilità, specialmente quando considerazioni pratiche, come il costo o gli effetti sulle persone, sono predominanti; è corretto che un avvocato nel dare consigli si riferisca alle pertinenti considerazioni morali ed etiche;
- un cliente può chiedere espressamente od implicitamente un consulto strettamente tecnico; quando tale richiesta viene effettuata da un cliente esperto in questioni legali, l'avvocato può accettare e prenderlo alla lettera. Quando tale richiesta viene effettuata da un cliente inesperto in materia giuridica, tuttavia, la responsabilità dell'avvocato come consulente ricomprende che egli indichi che possono essere coinvolte altre considerazioni rispetto a quelle strettamente legali.

Potrei anche aggiungere che l'approccio degli avvocati americani viene da lontano: i primi canoni della deontologia professionale dell'ABA risalgono invero al 1908 e si basano principalmente sul Codice Etico adottato dalla *Bar Alabama Association* nel 1887, che a sua volta aveva preso a prestito diverse cose dalle lezioni del 1854 del giudice George Sharswood³, e dalle 50 risoluzioni di David Hoffman⁴ contenute in un'opera intitolata *A course of legal study* (2d ed. 1836), manuale questo ultimo che non solo è considerabile come un monumento di etica, ma pure come un inno alla interdisciplinarietà e allo studio degli autori antichi che fanno parte anche del nostro patrimonio.

E quindi non possiamo affermare che sia una novità dell'ultima ora: in quasi duecento anni avremmo potuto confrontarci, su quello che è poi, lo ribadisco, il nostro patrimonio.

Ma un fenomeno analogo è avvenuto, in verità, con gli ADR dato che l'Università di Harvard nel rivitalizzare le regole di negoziazione ha fatto l'occhiolino a Omero e Sun Tzu.

E noi che abbiamo una tradizione ininterrotta che va dai *disceptatores domestici* romani ai mediatori civili e commerciali, abbiamo preferito combattere contro noi stessi piuttosto che diventare consapevoli della nostra forza millenaria.

³ Pubblicate col titolo di *Professional Ethics*.

⁴ V. *amplius* su

http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct/model_rules_of_professional_conduct_preamble.html

Premesso il mio immenso rammarico vorrei qui tratteggiare lo scenario degli ADR americani⁵ e poi passare a descrivere per sommi capi ciò che gli avvocati neutri od accompagnatori alla procedura sono tenuti a mettere oggi, nel 2012, a disposizione dei loro clienti. Le indicazioni non suoneranno per niente strane, seppure di non immediata acquisizione, ai mediatori italiani ed anche ai colleghi non mediatori che abbiano partecipato anche ad una sola mediazione.

Alla fine degli anni '90 con l'*Administrative Dispute Resolution Act* (ADRA, 1998)⁶ si sono istituzionalizzati diversi strumenti alternativi⁷ che dunque sono entrati a far parte del processo in ogni causa civile⁸: l'arbitrato⁹, la *early neutral evaluation*¹⁰, il *summary jury trial*, il *minitrial* (procedimenti di consultazione), ma la procedura che riveste importanza preponderante è la *mediation*.

Si pensi che il Dipartimento di Giustizia crede così tanto nella *mediation* che ha dato, tra le altre iniziative, origine ad un programma che attiene alle violazioni federali in materia di discriminazione dei disabili¹¹. Il Dipartimento di Giustizia in sostanza non può citare in giudizio i trasgressori a meno che i negoziati per risolvere la controversia non siano falliti. Dunque si tratta di una condizione di procedibilità che peraltro riguarda un potere pubblico in una materia che non è certo *iure privatorum*. In caso di accordo peraltro esso può essere dotato di esecutività¹².

⁵ L'ascolto delle arringhe degli avvocati che hanno dibattuto in Corte Costituzionale mi ha fornito un prezioso spunto per una piccola disamina.

⁶ Adottato dal Congresso a Washington il 27 gennaio 1998... nel rispetto dell'uso dei processi di risoluzione alternativa delle dispute nelle Corti distrettuali degli Stati Uniti, e per altri scopi.

⁷ Anche se non si forniscono i mezzi di finanziamento e questo è un grave limite per il funzionamento dei programmi.

⁸ Cfr. R. M. LEVY, *USA*, in *Overview of judicial mediation in the world*, L'Harmattan, 2010, Paris, p. 256 e ss.

⁹ Oggi si svolge soltanto su concorde volontà delle parti. Non può riguardare la violazione di diritti costituzionalmente garantiti e c'è comunque un tetto massimo per valore.

¹⁰ In generale è la seconda procedura più utilizzata, mentre le *summary jury trial* ed il *minitrial* sono considerate troppo costose.

¹¹ Il programma ADA (<http://www.ada.gov/medprog.htm>) che riguarda le persone affette da disabilità è seguito dai mediatori addestrati di diverse località dei seguenti stati: ALABAMA, ARIZONA, ARKANSAS, CALIFORNIA, COLORADO, CONNECTICUT, DISTRICT OF COLUMBIA, FLORIDA, GEORGIA, IDAHO, ILLINOIS, INDIANA, IOWA, KANSAS, KENTUCKY, LOUISIANA, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, MICHIGAN, MINNESOTA, MISSOURI, NEBRASKA, NEVADA, NEW HAMPSHIRE, NEW JERSEY, NEW MEXICO, NEW YORK, NORTH CAROLINA, OHIO, OKLAHOMA, OREGON, PENNSYLVANIA, SOUTH CAROLINA, SOUTH DAKOTA, TENNESSEE, TEXAS, UTAH, VERMONT, VIRGINIA, WASHINGTON, WISCONSIN. Questo programma riguarda mediazioni tra entità private e entità pubbliche.

¹² <http://www.ada.gov/enforce.htm>

Le più importanti agenzie pubbliche¹³ hanno un programma di ADR per la gestione delle controversie interne e per quelle nei confronti dei terzi¹⁴.

Le principali agenzie pubbliche gli ADR hanno messo in luce dieci vantaggi che sono dimostrabili con i risultati raggiunti:

I reclami sono trattati in modo più rapido e risolti prima.

Le spese processuali e gli altri costi sono bassi.

I reclami futuri sono evitati dalle parti che imparano a comunicare meglio tra di loro.

Le parti sono più soddisfatte del processo di *problem solving* e dei risultati.

I rapporti con i collaboratori e le altre parti esterne sono migliorati.

La procedura porta a soluzioni più creative.

La morale interna è migliorata.

Il *turnover* è inferiore.

Le parti rispettano maggiormente i loro accordi.

La produttività è migliorata¹⁵.

L'inserimento delle procedure ADR nell'ordinamento ha comportato che meno del 3% delle controversie USA sfoci in un processo.

Ogni Corte distrettuale americana autorizza, attraverso l'adozione di una regola locale, l'uso delle procedure alternative in ogni controversia civile incluso il processo fallimentare, tenendo però presente che l'arbitrato segue però regole peculiari¹⁶.

¹³ US POSTAL SERVICE, DEPARTMENT OF THE AIR FORCE, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF ENERGY, FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY, FEDERAL LABOR RELATIONS AUTORITÀ, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY.

¹⁴ V. il Rapporto che nel 1999 è stato indirizzato al Presidente degli Stati Uniti dalla INTERAGENCY ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION WORKING GROUP in <http://www.adr.gov/presi-report.htm>

¹⁵ TEN COMMON BENEFITS OF ADR

Complaints are processed more quickly and resolved earlier.

Litigation and other costs are lower.

Future complaints are avoided as parties learn to communicate better with each other.

Parties are more satisfied with the problem solving process and with the results.

Relations with contractors and other outside parties are improved.

The process leads to more creative solutions.

Internal morale is improved.

Turnover is lower.

Parties comply better with their settlement agreements.

Productivity is improved.

<http://www.adr.gov/presi-report.htm>

¹⁶ § 654 United States Code.

Ogni Corte distrettuale americana implementa un proprio programma di risoluzione alternativa¹⁷ delle dispute adottandolo con regola locale ed incoraggia la promozione dell'uso di strumenti di risoluzione alternativa delle dispute nel proprio distretto¹⁸.

Ogni Corte Distrettuale designa un dipendente, o un ufficiale giudiziario, che sia esperto di pratiche e processi di risoluzione alternativa delle controversie perché implementi, gestisca, monitori e valuti la risoluzione alternativa delle controversie del programma della Corte.

Questa persona esperta può essere responsabile anche per il reclutamento, la selezione, la formazione degli avvocati che servono come neutri ed arbitri nei programmi di risoluzione alternativa delle controversie.

Vi è poi il Centro giudiziario federale (*Federal Judicial Center*) e l'Ufficio Amministrativo dei Tribunali degli Stati Uniti (*Administrative Office of the United States Courts*) che sono autorizzati ad assistere i tribunali distrettuali della creazione e il miglioramento dei programmi alternativi di risoluzione delle controversie attraverso l'individuazione delle migliori pratiche e nel contempo di fornire ulteriore assistenza, come necessario e opportuno¹⁹.

Da queste prime indicazioni si evince dunque che negli Stati Uniti quando si parla di strumento di risoluzione alternativo delle dispute si intendono diversi istituti.

Si può dire inoltre che l'ADR americano investe tutto il settore civile (salva la limitazione sino a 150.000\$, che riguarda per valore e materia l'arbitrato), che ogni Corte distrettuale ha un programma proprio, che i programmi vengono "curati" anche dallo Stato.

Tutti i litiganti sono invitati a considerare l'uso di un processo di risoluzione alternativa delle controversie in una fase appropriata del contenzioso.

Ciò peraltro accade anche nel regno Unito per le tre fasce in cui vengono dopo la riforma del giudice Woolf, incasellate le controversie: *small claim track*²⁰, *fast track*²¹ e *multi track*²².

¹⁷ V. ad esempio quello delle Corti UTAH del 2012 in <http://www.justice.gov/olp/adr/docs/ut.pdf>

¹⁸ § 651 (b) United States Code.

¹⁹ § 651 lettera F)

²⁰ Riguarda le pretese al di sotto delle 5.000 sterline.

²¹ La fast track riguarda le dispute di valore superiore alle 5.000 sterline ed originariamente inferiore alle 15.000, dal 6 aprile 2009 la somma è stata innalzata a 25.000 sterline.

²² Attiene alle controversie sopra le 25.000 sterline.

Ogni tribunale distrettuale degli Stati Uniti fornisce ai litiganti in tutti i casi civili almeno un processo di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui, ma non limitato a, *mediation, early neutral evaluation, minitrial, and arbitration*²³.

Qualsiasi tribunale distrettuale, che sceglie in certi casi di richiedere l'utilizzo della risoluzione alternativa delle controversie, può farlo solo per quanto riguarda la *mediation*, l'*early neutral evaluation*, e se le parti consentono, l'arbitrato²⁴.

Da ciò si ricava che le parti possono richiedere di percorrere un ADR in una fase appropriata del contenzioso (di solito ciò avviene nella fase iniziale) e all'uopo ogni Corte deve mettere a disposizione almeno uno strumento alternativo.

Nel caso invece in cui sia la Corte a richiedere di utilizzare lo strumento ciò potrà avvenire solo con riferimento alla *mediation* e alla *early neutral evaluation*²⁵.

A prescindere dallo strumento che si utilizzi le Corti distrettuali devono approntare norme locali che prevedano la confidenzialità dei processi di ADR ed il divieto di rivelazione delle comunicazioni confidenziali inerenti alla risoluzione della disputa²⁶.

Ogni Corte distrettuale che autorizzi l'uso di ADR deve adottare specifiche procedure (*panel of Neutrals*) per far sì che i neutri siano utilizzabili dalle parti per ogni categoria di processo.

Ogni Corte distrettuale pubblica le proprie procedure per la selezione dei neutri sui propri *panels*²⁷.

Importantissimo precetto è quello sulla formazione dei neutri: ogni persona che funge da neutro in un processo di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero essere qualificato e addestrato a servire come neutro nell'appropriato processo di risoluzione alternativa delle controversie.

A tal fine, il tribunale distrettuale può utilizzare, tra gli altri, i giudici magistrato²⁸ che sono stati addestrati per servire come neutri nei processi di risoluzione alternativa delle controversie, neutri professionisti provenienti dal settore privato e le persone che sono

²³ Come autorizzato nelle sezioni da 654 a 658.

²⁴ § 652 a) e b) United States Code.

²⁵ In California per la verità anche l'arbitrato può essere obbligatorio.

²⁶ § 652 d) United States Code.

²⁷ § 653 a) United States Code.

²⁸ Si tratta di ufficiali giudiziari che assistono il giudice nell'istruire il caso e possono giudicare direttamente alcuni casi penali e civili quando le parti vi consentono.

stati addestrate per servire come neutri nei processi di risoluzione alternativa delle controversie.

Ogni corte indica individualmente le regole sulla incompatibilità a servire come neutri avendo di mira però la norma che riguarda la riconsuazione dei Giudici e gli standard di responsabilità professionale²⁹.

La legge americana prevede dunque che ogni Corte distrettuali abbia un elenco di neutri i cui requisiti sono stabiliti localmente e pubblicati.

Tuttavia la disciplina generale non stabilisce che il neutro debba provenire da una specifica professione e a ben vedere nemmeno che sia un professionista (*persons who have been trained to serve as neutrals in alternative dispute resolution processes*).

Premesse queste norme generali sui programmi di risoluzione alternativa delle controversie possiamo ora a parlare brevemente all'arbitrato.

In merito a questo strumento possiamo dire che può essere contrattuale o su ordine del giudice (*court-annexed arbitration*): in tale ultimo caso la decisione dell'arbitro non è vincolante per le parti, né incontestabile, ma ci sono per legge conseguenze in tema di spese processuali in capo all'attore e pure in capo al soccombente se la decisione del successivo giudizio non sia più favorevole di quella arbitrale.

Il deferimento arbitrale da parte del giudice comporta che le parti debbano acconsentirvi, ma l'arbitrato non può riguardare la violazione di diritti garantiti dalla Costituzione, deve attenere alla competenza del Giudice distrettuale e concernere una controversia ove la richiesta di risarcimento non superi i 150.000 \$³⁰.

Pertanto vige una presunzione che la richiesta di risarcimento sia sempre inferiore a 150.000 \$ a meno che non si produca documentazione che dimostri il contrario³¹.

L'arbitro che esprime funzioni quasi-giudiziarie è competente in relazione al distretto della Corte davanti a cui è stato intentato l'arbitrato ed ha qui il potere di condurre le udienze arbitrali, di ricevere i giuramenti e le affermazioni (*affirmations*³²), di emettere il provvedimento aggiudicativo.

²⁹ § 653 b) United States Code.

³⁰ § 654 a) United States Code.

³¹ § 654 c) United States Code.

³² Negli Stati Uniti si può "giurare di dire la verità" oppure "affermare di dire la verità" (giudizialmente e fuori dal giudizio): le formule sono equipollenti.

Gli arbitri prestano giuramento e possono essere ricusati come i giudici; sono soggetti inoltre a certificazione³³.

Veniamo ora a descrivere brevemente i procedimenti di consultazione.

Il neutro interviene qui non per emettere una decisione, quanto piuttosto per informare le parti sul modo in cui un estraneo valuta la loro controversia, e (talvolta) per indicare quella che sarebbe la sua decisione se gli venisse richiesta.

Così nei *summary jury trials* (giudizio consultivo) dove si formano alla fine della *discovery* delle finte giurie presiedute da un giudice che in un processo simulato a seguito di procedure abbreviate forniscono verdetti (pareri consultivi) che possono essere base per una negoziazione.

Lo stesso avviene nei *mini trials* (mini processi) nei quali gli avvocati delle parti discutono le loro difese di fronte ad un terzo neutrale (anche giudice) e ad un collegio formato dai direttori amministrativi, che poi procedono sulla base degli argomenti esposti a negoziare possibili soluzioni conciliative sotto la guida eventuale di un mediatore.

Nell'*early neutral evaluation* (valutazione preliminare neutrale) avvocati esperti forniscono valutazioni sui punti di forza e sui punti deboli delle pretese avanzate dalle parti nella questione rappresentata: la valutazione non è vincolante per le parti che possono tentare, se lo desiderano, di addivenire ad una regolazione della questione che sia più favorevole di quella esposta.

In ordine alla *mediation* possiamo dire quanto segue.

Il giudizio americano (*adversary*) favorisce di per sé gli accordi transattivi.

Abbiamo, infatti, una prima fase detta *pre-trial conference* in cui le parti procedono alla cosiddetta *discovery*, si scambiano, come accennato, le informazioni sulle rispettive prove: ciò può già portare come si può intuire ad un accordo.

L'attore può fare una proposta che il convenuto è libero di rifiutare: ci sono però delle sanzioni per il rifiuto irragionevole o di mala fede³⁴.

Il giudice in questa fase si limita a rilevare l'intervenuto accordo.

In questo sistema si va a collocare la *mediation*, in particolare verso la parte conclusiva della *discovery*.

³³ § 655 United States Code.

³⁴ V. la *rule 68* delle *Federal Law*.

In base all'ADRA le Corti devono rispettare il carattere stragiudiziale ed endoprocessuale della *mediation*, ma per il resto possono modellare i programmi (volontari od obbligatori) di *court annexed* secondo le loro capacità economiche ed organizzative: così alcuni uffici hanno dato al giudice la possibilità di imporre il ricorso allo strumento³⁵ ed altri solo di consigliarlo³⁶.

In alcune corti le parti possono ricorrere allo strumento di comune accordo oppure a seguito di indicazione non vincolante del giudice³⁷; anche la sospensione del processo viene concordata.

Le parti hanno pure la facoltà di scegliere il mediatore³⁸ tra i giudici della corte³⁹.

Solo in caso di non accordo sul nome del terzo interviene a nominarlo l'ufficio che gestisce il programma.

Ancora abbiamo detto che in ogni Corte viene di solito individuato un amministratore che può essere un giudice od un impiegato del tribunale che amministra, sorveglia e valuta i programmi di ADR della Corte stessa.

Possiamo aggiungere che l'amministratore si occupa anche di autorizzare a servire come "neutri"⁴⁰ i giudici, il personale della Corte, nonché i terzi privati.

Vi è anche un Ente di formazione federale (*Federal Judicial Center - "FJC"*), che offre corsi di formazione per giudici federali ed altri servizi relativi all'amministrazione degli ADR⁴¹.

³⁵ Le sanzioni per lo più pecuniarie contro la mancata partecipazione sono state indirizzate sia contro le parti, sia contro i loro difensori

³⁶ Magari a seguito di seduta preliminare in cui le parti vengono informate circa lo strumento.

³⁷ V. la nostra mediazione delegata di cui all'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

³⁸ Opera volontariamente o su convenzione con la Corte, perché come abbiamo detto i programmi del 1998 non sono stati finanziati.

³⁹ Oppure tra i mediatori esterni accreditati o ancora presso centri esterni.

⁴⁰ Ogni corte è libera di adottare in merito le proprie regole e pratiche, nel senso che ci sono corti che hanno giudici ed amministratore che si occupano di ADR e Corti che hanno soltanto un giudice che si occupa di sorvegliare il programma di ADR. Ci sono alcune Corti ove i mediatori appartengono ai dipendenti della Corte, altre che hanno un *panel* di mediatori che sono disponibili a mediare diverse controversie ed altre, in specie quelle federali, ove sono gli stessi giudici ad operare come mediatori per la maggiorparte delle procedure.

⁴¹ Inoltre il FJC fornisce guide scritte per gestire la mediazione e conduce studi per determinare le pratiche migliori e più efficaci. Il FJC ha anche creato un gruppo di consulenti in mediazione che sono a disposizione dei tribunali che desiderano impostare programmi di mediazione o migliorare i programmi che già hanno. I consulenti vengono messi in contatto con l'assistenza giudiziaria richiedente. Di solito visitano il distretto e scrivono un dettagliato rapporto confidenziale in cui valutano il programma della corte e formulano raccomandazioni (valutano anche il sito web delle Corti).

I consulenti FJC sono utili anche per aiutare i tribunali bilanciare l'utilizzo dei giudici con programmi di mediazione in cui si costituiscano pannelli di mediatori che offrono il proprio servizio alla corte.

Spesso già alla prima udienza di pianificazione del processo (*scheduling conference*) il giudice discute con gli avvocati del procedimento alternativo, così come del processo e ciò si ripete ad ogni stadio del processo⁴²; il che determina che gli avvocati debbano essere preparati su entrambi i versanti.

Ciò comporta anche che gli avvocati durante il processo siano spesso messi sull'avviso circa i punti forti e deboli dei loro clienti e circa i costi che si dovrebbero sostenere per passare alla fase più propriamente processuale: il che determina che circa il 98% delle questioni si risolve prima di andare a processo (*trial*).

Normalmente si distingue tra giudice assegnatario del caso (*district judge*) e giudice mediatore (*magistrate judge*) che si occupa della fase *pre-trial*: sono dunque di solito soggetti diversi, il che impedisce contaminazioni tra la fase ADR e quella di giudizio⁴³.

I giudici mediatori si incontrano in un breve lasso di tempo con gli avvocati ed identificano i punti chiave della controversia, sviluppano un piano di gestione del caso ed esplorano le possibilità di accordo.

Il tutto mentre attendono alla *discovery*, decidono sulle richieste delle parti e cercano di condurre le parti verso un accordo; accordo che se non interverrà consentirà comunque alle parti di chiedere al giudice distrettuale un provvedimento sommario (*summary judgment motion*) o un vero e proprio processo.

Di fronte a ciò l'affermazione ascoltata in un'arringa tenuta davanti alla Corte Costituzionale il 23 ottobre scorso per cui negli Stati Uniti non ci sarebbe rapporto tra mediazione e processo, ma una scissione, appare al mio modesto comprendonio poco incomprensibile.

Se l'accordo riesce le parti possono decidere di tenerlo riservato⁴⁴ oppure di farlo recepire da un procedimento del giudice⁴⁵.

Nel caso fallisca, si ritiene in generale che le informazioni acquisite nel corso del procedimento non debbano poter essere utilizzate⁴⁶ dal giudice ai fini probatori, ma solo per orientarlo nella decisione sulle spese processuali⁴⁷.

⁴² In apposite udienze (*settlement conferences and mediation*).

⁴³ Nel Distretto est di New York se sorgono questioni etiche, tributarie o altri problemi legali nel corso di una mediazione condotta da un membro del panel della Corte, è il Giudice ADR, non il giudice incaricato del caso, che prenderà una decisione sul punto. Cfr. R. M. LEVY, *USA*, in Overview cit., p. 259.

⁴⁴ Salvo chiederne la risoluzione o l'adempimento in successivo giudizio.

⁴⁵ In tal caso se ne può chiedere l'esecuzione coattiva.

Gli avvocati, i mediatori, i tribunali, gli stessi gerenti dei programmi di mediazione e altri possono suggerire che le parti leggano alcune guide sulla preparazione delle mediazioni che sono progettate dell'*American Bar Association* per rendere l'incontro il più produttivo possibile⁴⁸.

Dalla guida inerente la mediazione assistita da avvocato⁴⁹ si possono evincere alcuni obblighi e/o comportamenti che i cittadini americani possono pretendere dagli avvocati a cui si affidano appunto come clienti ovvero dagli avvocati che agiscono come neutri in mediazione.

1) L'avvocato accompagnatore deve conoscere le regole del programma della Corte ove la mediazione si svolge⁵⁰, le regole di procedura della Corte e le eventuali regole di procedura e lo stile del mediatore incaricato⁵¹.

Ne deve parlare con il suo cliente ed in ogni caso deve porsi le seguenti domande:

- Le parti produrranno una nota al mediatore prima della sessione di mediazione in cui si delineano i punti controversi e inerente a qualunque argomento il mediatore possa richiedere?
- Questa nota sarà confidenziale per il mediatore o da scambiare con controparte?
- Il mediatore chiederà di firmare un accordo per mediare? Se così fosse l'avvocato può chiedere al mediatore di fornirne una copia prima della mediazione in modo da poterlo analizzare e vedere se ci sono domande da fare in merito.
- Quali informazioni dovranno riservarsi alla seduta di mediazione?

⁴⁶ La riservatezza e confidenzialità della procedura è affidata dall'*ADRA* comunque ai regolamenti delle singole Corti.

⁴⁷ V. *amplius* F. CUOMO ULLOA, *LA CONCILIAZIONE, Modelli di composizione dei conflitti*, CEDAM, Padova, 2008 p. 95 e ss.

⁴⁸ Cfr. http://www.americanbar.org/groups/dispute_resolution/resources.html

⁴⁹ Negli Stati Uniti non vige l'assistenza obbligatoria in mediazione. "*Representation by an attorney is permitted, but not required, in mediation*" recita perentoriamente anche il programma ADA in <http://www.ada.gov/medprog.htm>.

⁵⁰ Different states, courts, and mediation programs may have different mediation rules, so you should ask your attorney about any rules governing your mediation.

⁵¹ In most cases, the parties play some role in deciding how the mediation process in their case will be conducted. Many states, courts, and mediation programs have rules about these procedures, so you should check with your attorney about any rules governing your mediation. The mediator may also have procedures that he or she normally follows. However, some decisions about the mediation procedures may still be up to the parties and the mediator.

Some mediators have web sites or provide bios that indicate their mediation approach.

If you are represented by an attorney, your attorney may know the styles of mediators available for your case and can help you choose one whose style fits your needs.

- Chi sarà presente alla sessione di mediazione? La mediazione è effettiva quando il rappresentante della parte ha pieni poteri, è ben informato e può prendere decisioni indipendenti sul caso. Se non può partecipare per il cliente una persona dotata di pieni poteri, l'avvocato dovrebbe parlarne prima della sessione col mediatore.
- Qualcuno parteciperà via video o telefono o "a chiamata" in caso di necessità?
- Parteciperanno alla mediazione oltre agli avvocati delle parti anche altri professionisti?
- Ha il mediatore avuto una precedente relazione con qualcuno (parti, avvocati e consulenti) dei partecipanti alla mediazione?
- Quando inizia la sessione e quanto durerà?
- Dove si terrà la sessione di mediazione?
- Ogni parte potrà presentare i suoi punti di vista nella sessione congiunta? Se sì che cosa può essere di aiuto dire al mediatore?
- Quali argomenti si devono riservare per i *caucus* col mediatore?
- Che cosa potrebbe fare il mediatore per aiutare il cliente?
- Se le parti raggiungeranno un accordo chi lo preparerà?
- Quanto costa la mediazione, nel caso? Come si dividono i costi?⁵².

⁵² Will each party provide a memo to the mediator before the mediation session outlining the issues in dispute and whatever other topics the mediator requests?

Will this memo be confidential to the mediator or exchanged with the other party?

Will the mediator ask you to sign an agreement to mediate? If so, your attorney might ask the mediator to provide a copy before the mediation session so you can review it and ask any questions you may have about it.

What information should you bring to the mediation session?

Who will be at the mediation session? Mediation is most effective when each party has in attendance someone with full settlement authority who is knowledgeable and can make independent decisions about the case.

Will anyone participate by video, telephone, or be "on call" if needed?

If a person on your side with authority to settle cannot attend in person, your attorney should discuss this with the mediator before the mediation session.

Should any professionals other than the parties' lawyers attend the mediation?

This might include financial or technical professionals, among others.

Does the mediator have a prior relationship with anyone who will be at the mediation (such as parties, professionals, attorneys)? If so, you should tell your attorney as soon as you discover this. Despite the information you disclose, the mediator may still be able to be impartial and helpful but you, the other party, and the mediator will want to know about this from the beginning.

What time will the mediation session begin? How late might the session last?

Where will the mediation session(s) be held?

Will each party present its views in a joint session? If so, what would be most helpful for you (or your lawyer) to say?

2) Quando la parte è in grado di partecipare al processo di selezione del mediatore, l'avvocato accompagnatore è tenuto a discutere in merito:

- a quali esperienze e qualità devono contraddistinguere un mediatore che sia in grado di aiutare le parti a risolvere la disputa;
- alla sussistenza o meno in capo al mediatore eventualmente conosciuto di tali esperienze e qualità⁵³.

3) L'avvocato accompagnatore deve spiegare alla parte - se non abbia mai partecipato ad una mediazione - che può ricavare maggiore profitto da una preparazione preventiva della mediazione⁵⁴.

4) L'avvocato accompagnatore deve spiegare alla parte che abbia già partecipato ad una mediazione che una preparazione preventiva è utile perché le questioni, le parti ed il mediatore sono comunque differenti⁵⁵.

5) L'avvocato accompagnatore deve essere consapevole del fatto ed è tenuto a spiegare al cliente che non esiste un modo migliore di un altro per preparare la mediazione e che comunque la preparazione è assai impegnativa⁵⁶.

6) Durante la preparazione della mediazione l'avvocato accompagnatore è tenuto a:

- raccogliere le informazioni rilevanti;
- sviluppare una strategia negoziale;
- aiutare il cliente ad avere una visione comune di quello che ognuno può aspettarsi dall'altro e dunque dei ruoli di ognuno;
- considerare alcune questioni anche se non possono avere una risposta anticipata e la cui risposta può variare nel corso della procedura:

What items should you reserve for a private caucus with the mediator?

What can the mediator do that would be particularly helpful for you?

If the parties reach agreement, who would prepare it?

How much does mediation cost, if anything? How will the parties divide the costs?

⁵³ If you can participate in selecting the mediator, discuss with your lawyer what experience and qualities in a mediator would be most important in helping the parties resolve their dispute.

If you know of particular mediators, discuss whether any of them have the experience and qualities you think would be most helpful in your case.

⁵⁴ You are more likely to feel satisfied with mediation if you prepare carefully ahead of time. This is especially important if you have never participated in a mediation.

⁵⁵ Even if you have mediated many times, it is still important to prepare for each mediation because the issues, parties, and mediators are different in each case.

⁵⁶ There is no one best way to prepare for mediation or to mediate. You should work closely with your attorney to prepare for the mediation.

1. Quale è il reale conflitto?
2. Ci sono problemi causati dalla sfiducia o da una cattiva comunicazione?
3. Che cosa si vorrebbe realizzare nella mediazione?
4. Che cosa il mediatore deve conoscere per aiutare il cliente a raggiungere l'obiettivo?
5. Che cosa deve conoscere l'altra parte?
6. Di che cosa ha bisogno il cliente per essere soddisfatto?
7. Di che cosa ha bisogno l'altra parte per sentirsi soddisfatta?
8. Nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo il cliente vuole mantenere una relazione con la controparte dopo la risoluzione della controversia?
9. Su quali questioni le parti si possono accordare?
10. Su quali questioni il cliente non può accordarsi?
11. Quali informazioni, documenti, casi, o regole potrebbero far cambiare idea alla controparte sulle questioni coinvolte nella disputa?
12. Che cosa potrebbe causare un cambiamento nel cliente?⁵⁷

7) Anche se il cliente è convinto che le altre persone abbiano torto, l'avvocato accompagnatore sa che per una buona riuscita della mediazione deve esplorare i punti di vista altrui. L'avvocato accompagnatore deve dunque avvertire il cliente che in mediazione:

- può ascoltare opinioni che non condivide;

⁵⁷ In addition to helping you collect relevant information, develop a negotiation strategy, and consider the issues listed below, working together will help you have a common understanding of what to expect of each other in the mediation process. For example, you will want to discuss what roles each of you will play during the mediation.

Think carefully about the issues listed below in preparing for mediation. You may not be able to give a definite answer to some of the following questions and your answers may change during the mediation process, but it is still helpful to consider seriously these questions ahead of time.

What is the conflict really about? Are some of the problems caused by mistrust or miscommunication? What would you like to accomplish at the mediation? What does the mediator need to understand to help you accomplish your goals? What does the other party need to understand? What would you need to feel satisfied with the outcome? What do you think that the other person needs to feel satisfied? This may involve the exchange of monetary or nonmonetary value. If you can reach an acceptable agreement in mediation, would you want to have any relationship with the other party after the dispute is resolved? What issues do you and the other party agree about? What issues do you disagree about? What information, documents, cases, or rules might cause the other party to change his or her mind about the issues in dispute? What might cause you to change your mind?

- è più produttivo sforzarsi di comprendere le opinioni altrì anche se non si condividono;
- il mediatore vuole ascoltare ciò che è realisticamente possibile;
- è meglio ascoltare con attenzione la controparte e cercare di individuare gli argomenti su cui concorda: ciò può indurre la controparte a capire le opinioni del cliente e a chiudere un accordo;
- è meglio trattare la controparte con rispetto quando si è in disaccordo: il rispetto attira rispetto;
- è meglio mantenere una mente aperta e desiderosa di considerare varie opzioni di un accordo⁵⁸.

8) L'avvocato accompagnatore ha il dovere di informare il cliente che il mediatore, a seconda della fattispecie, può essere indotto a fornire suggerimenti ed opinioni sul caso, ma che il cliente ha diritto di ignorarle e di prendere le proprie decisioni, inclusa la decisione di non accettare una particolare offerta e di non raggiungere un qualsivoglia accordo⁵⁹.

9) Nel caso in cui la mediazione porti ad un parziale risultato il cliente ha il diritto di chiedere all'avvocato che valuti l'opportunità di chiedere, oralmente o per iscritto, una nuova sessione di mediazione⁶⁰.

10) L'avvocato mediatore ha il dovere di spiegare alle parti tutti gli aspetti inerenti la confidenzialità della procedura di mediazione⁶¹.

⁵⁸ In mediation, you may hear things that you will disagree with and the mediator may test your views about what is realistic. Although you may think that the other party is wrong about some things, you will be more successful if you try to understand the other party's views. Listen carefully to what he or she says and look for things that you agree on. This may cause the party person to try to understand your views and it may help you reach an agreement. When you disagree, it helps to be respectful toward the other party, which may cause him or her to treat you respectfully as well.

Keep an open mind and be willing to consider various options for settlement.

⁵⁹ Even if your mediator gives you suggestions or opinions, you always have the right to disregard those suggestions and opinions and to make your own decisions, including a decision not to accept a particular offer or not to reach any settlement.

⁶⁰ If you do not resolve all the issues at a mediation session, think about whether your attorney should follow up with the mediator by phone or to schedule another mediation session. Sometimes parties need more information or time to think about a situation before they are ready to finally resolve a dispute.

⁶¹ Your mediator is likely to discuss all these aspects of confidentiality with you but, if he or she does not, be sure to ask.

11) L'avvocato mediatore può aiutare a mettere per iscritto l'accordo raggiunto se gli avvocati non accompagnano le parti; se le parti sono rappresentate da avvocati sono questi ultimi che ordinariamente preparano l'accordo scritto⁶².

⁶² If the parties reach an agreement settling their dispute, the mediator may help the parties put it in writing. If attorneys are representing the parties, the attorneys typically draft any written agreement.